Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari1vciv@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5042017-54.2022.8.21.0027/RS

REQUERENTE: ADRIANA VARGAS DE VARGAS

REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS

SENTENÇA

Vistos e examinados os autos.

ADRIANA VARGAS DE VARGAS ajuizou ***ação de obrigação de fazer com tutela de urgência*** em face do I**NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS,** ambas as partes já qualificadas na Petição Inicial (evento 1, INIC1). Afirmou que possui 48 anos de idade e que se encontra acometida da patologia denominada Carcinoma Ductal Invasor de mama D-CID: C 50.9. Sustentou que necessita do fornecimento do medicamento 2 IBRANCE EXBC 125 mg. 21 caps. 21,00), por 21 dias a cada 28 dias. Discorreu sobre a responsabilidade do IPE-Saúde para a concessão do tratamento postulado. Vindicou a concessão da gratuidade judiciária. Pleiteou a concessão da tutela de urgência para determinar que o réu realize a dispensação da medicação 2 IBRANCE EXBC 125 mg. 21 caps. 21,00), por 21 dias a cada 28 dias. Requereu a procedência da ação para condenar o réu a fornecer o fármaco enquanto perdurar a necessidade de utilização desta medicação conforme prescrição médica. Anexou documentos. (evento 1, INIC1).

Recebida a inicial, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça e concedida a tutela de urgência postulada (evento 4, DESPADEC1).

Citado, o **IPE-SAÚDE** apresentou contestação (evento 13, CONT1). Inicialmente, discorreu acerca do cumprimento da tutela de urgência, bem como sobre a necessidade de retificação do polo passivo da demanda para que passe a constar IPE-SAÚDE. No mérito, sustentou a ausência de cobertura do plano de saúde do instituto demandado em relação ao medicamento oncológico postulado. Argumentou que a pretensão autoral é ilegal pois pretende o custeio de medicamento que não está previsto na tabela de cobertura da autarquia demandada. Ponderou que o Ipê-Saúde é regido pelas normas de Administração Pública, pelo princípio da isonomia e da legalidade. Dissertou que se enquadra como plano de saúde de autogestão de direito público que não se aplica às normas de direito privado, tampouco o Código de Defesa do Consumidor. Reproduziu jurisprudência a confortar sua tese. Ponderou sobre as alterativas para tratamento de câncer de mama inseridas na cobertura do plano do IPÊ-SAÚDE. Salientou que o fármaco Fulvestranto + Palbociclib não está previsto nas Recomendações Técnicas em Oncologia vigentes. Requereu a retificação do polo passivo do feito. No mérito, pediu o julgamento de improcedência do pedido. Subsidiariamente, em caso de procedência do pedido, pugnou pela realização de renovação periódica do laudo médico para continuidade do tratamento.

Houve réplica (evento 16, RÉPLICA1).

O Ministério Público declinou a intervenção no feito (evento 81, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Adriana Vargas de Vargas em face do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul-IPERGS, objetivando o fornecimento do medicamento 2 IBRANCE EXBC 125 mg. 21 caps. 21,00), uma vez que, tal pedido, restou indeferido na via administrativa.

A parte autora afirma na petição inicial ser portadora de "Carcinoma Ductal Invasor de mama D-CID: C 50.9" e portanto, necessita do medicamento 2 IBRANCE EXBC 125 mg. 21 caps. 21,00), por 21 dias a cada 28 dias para o tratamento da sua saúde.

O IPE-SAÚDE arguiu que o medicamento postulado não se encontra coberto pelo plano, bem como não está previsto no Protocolo Oncológico do Instituto.

Inicialmente, cabe salientar que o artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o IPÊ-Saúde, refere que integram o plano de saúde atendimento médico, hospitalar, atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, assim como ações de prevenção da doença e promoção à saúde: (…) Artigo 4º- O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor. (…)

Todavia, o parágrafo único do artigo 4º da citada Lei Complementar restringe o fornecimento de tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais aos que estejam previsto nas tabelas do Instituto.

Insta frisar que, malgrado exista a previsão de exclusão na legislação de regência, somente justifica-se sua incidência quando não comprovada a necessidade do fornecimento dos tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais para o tratamento da patologia, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ- **SAÚDE**. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTO** PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER JAKAVI® (RUXOLITINIBE). PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. **A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários.** Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado, notadamente porque as Recomendações são de 2010, logo desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico quando evidente a ausência de atualização do Protocolo e suas Recomendações em Oncologia. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela requerida, uma vez que restou comprovada a necessidade e a urgência do **medicamento** solicitado, através de laudo médico especializado, razão pela qual imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079951091, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019)" [grifo nosso]*

> *"APELAÇÃO CÍVEL. IPÊ-SAÚDE. LINFOMA NÃO-HODGKIN. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTO**. IBRUTINIBE. NEGATIVA DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. **I. A Lei nº 12.134/2004, que reestruturou o IPERGS, dispõe que o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, engloba um conjunto de ações visando à prevenção de doenças, à promoção, educação e assistência à saúde de seus usuários (arts. 1º e 2º). II. Em que pese a edição da Lei Complementar nº 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão nos protocolos ou listas da autarquia previdenciária e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurado da autarquia**. III. Honorários advocatícios reduzidos. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70080627953, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 27/03/2019)"[grifo nosso]*

Ademais, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento de que não cabe ao plano de saúde selecionar o tratamento que será dispensado ao segurado para a patologia coberta pelo plano, como ilustram as seguintes ementas de julgados proferidos pelo Tribunal da Cidadania:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE **SAÚDE**. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. **3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.** 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE **SAÚDE**. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. **3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo**. 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*

Dessa forma, extrai-se dever do IPE-SAÚDE em fornecer o tratamento postulado pela parte autora mesmo que este não esteja coberto pelo plano ou que não esteja previsto no Protocolo Oncológico do Instituto, desde que comprovada sua necessidade.

Na hipótese dos autos, a autora acostou relatório médico (evento 1, LAUDO7) que comprova que está acometida de Carcinoma Ductal Invasor de mama D-CID: C 50.9, conforme trancrevo trecho do relatório: (...) Paciente com diagnóstico de Carcinoma Ductal Invasor de mama D-CID: C 50.9, em 2015. Apresenta recaída Pulmonar, hepática, linfonodal e óssea, Nov/2022. Tem indicação do uso de Fulvestranto + Palbociclib, sendo este na dose de 125/mg (um) comprimido por 21 dias a cada 28 dias. Necessita do uso de 12 (doze) caixas do Palbociclib com 21 comprimidos cada uma para o uso de 12 meses. O Fulvestranto é pago/estão no rol do IPERGS, custeado por ele. A indicação está fundamentada em estudos clínicos, sendo que a medicação acima referida, está em uso corrente, com recomendação de várias Sociedades de Oncologia Clínica do mundo (...)".

Portanto, diante do relatório médico juntado (evento 1, LAUDO7) pela autora aliado às informações mencionadas, resta demonstrada a necessidade da autora em realizar o seu tratamento de saúde com o fármaco postulado.

Registro que a condição da autora como segurada do plano de **saúde** réu foi demonstrada pelo documento do evento 1, OUT5 .

Consigno que mesmo demonstrada a necessidade do tratamento pela parte autora, restou indeferida na esfera administrativa o fornecimento do medicamento indicado na exordial (evento 1, OUT8).

No entanto, como já exposto, embora não previsto *"nas recomendações técnicas de oncologia do IPÊ-RS"*, tal circunstância não é suficiente para elidir a responsabilidade da Autarquia ré em fornecer o medicamento ou tratamento adequados para a doença da demandante.

Em síntese, comprovada a necessidade do tratamento pela parte autora, bem como a responsabilidade em fornecê-lo pela Autarquia ré, impõe-se a procedência do pedido vertido na peça vestibular.

Dispositivo.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **ADRIANA VARGAS DE VARGAS** em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - IPÊ-SAÚDE** para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida, tornando-a definitiva e condenar a parte ré para que forneça o medicamento 2 IBRANCE EXBC 125 mg. 21 caps. 21,00), por 21 dias a cada 28 dias, enquanto perdurar a necessidade, na quantidade e especificações descritas no receituário médico atualizado.

Isento o Instituto de Assistência à saúde dos Servidores Público do Rio Grande do Sul-IPÉ Saúde ao pagamento da Taxa Única.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 600,00, nos termos do §8° do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Retifique-se o polo passivo da demanda para passar a constar **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - IPÊ-SAÚDE.**

Havendo apelação, considerando as novas disposições do Novo Código de Processo Civil (art. 1.010), que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no primeiro grau, deverá o Cartório intimar a parte recorrida para oferecer contrarrazões e dar vista ao Ministério Público para parecer, se for o caso, e, na sequência, remeter os autos à instância superior.

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, deve ser submetida ao reexame necessário, consoante entendimento cristalizado na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao Colendo Tribunal de Justiça para reexame.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO TEIXEIRA DELABARY, Juiz de Direito**, em 11/10/2023, às 11:11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10042149929v15** e o código CRC **e264a172**.